

プライバシーの権利Ⅱ

－憲法35条1項の保護法益－

海野 敦史

G P S 捜査は、対象車両の時々刻々の位置情報を検索し、把握すべく行われるものであるが、その性質上、公道上のもののみならず、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて、対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にする。このような捜査手法は、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得るものであり、また、そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点において、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。

憲法35条は、「住居、書類及び所持品について、侵入、搜索及び押収を受けることのない権利」を規定しているところ、この規定の保障対象には、「住居、書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利が含まれるものと解するのが相当である。そうすると、前記のとおり、個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるG P S 捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる（中略）とともに、一般的には、現行犯人逮捕等の令状を要しないものとされている処分と同視すべき事情があると認めるのも困難であるから、令状がなければ行うことのできない処分と解すべきである。

GPS捜査事件判決からの問題提起

- ・判例は「個人のプライバシー」を問題としながら、なぜ憲法13条（私生活上の自由）に言及せず、憲法35条1項に依拠したのか？
- ・判例は本件で「個人のプライバシーの侵害」の内実をどのように捉えているか？
- ・判例は当該侵害に該当し得る捜査手法として、**GPS**捜査と「公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法」との相違をどのように捉えているか？
- ・判例はなぜ「住居、書類及び所持品」を超えて、これに準じる「私的領域」を観念し、「私的領域に『侵入』されることのない権利」を導く必要があったのか？
- ・判例のいう「私的領域への侵入」とは具体的にどのような行為を意味するのか？ ここでいう「侵入」とはもっぱら物理的な侵入を意味するのか？
- ・判例は「私的領域に『侵入』されることのない権利」が問題となる局面について、もっぱら刑事手続のみを念頭においているのか？
- ・仮に自己情報コントロール権説の立場からこの判例で問題となった公権力の**GPS**捜査行為を捉えた場合、どのような帰結が導かれ得るか？

憲法35条1項に基づく権利

憲法35条1項の規定

何人も、**その住居、書類及び所持品について、侵入、搜索及び押収を受けることのない権利**は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ搜索する場所及び押収する物を明示する**令状がなければ、侵されない**。

- ・ 住居、書類及び所持品について、侵入、搜索及び押収を受けることのない権利
＝**住居不侵入等確保権**

【参考】米国憲法修正4条の規定（母法、訳）

身体、住居、書類及び所持品について、不合理な搜索（searches）及び拘束・押収（seizures）を受けることのない**人民の権利**は、侵されない。いかなる令状も、宣誓又は確約によって裏づけられる相当な理由（probable cause）に基づき、かつ、搜索されるべき場所及び拘束・押収されるべき人又は物を具体的に表示するものでなければ、発せられてはならない。

⇒米国の判例では修正4条がプライバシーの保護の根拠規定。日本でも**憲法35条1項にプライバシー保護の意味合いが含まれている**ことは承認されているが、この規定に基づき「プライバシーの合理的な期待」が保護されるとは一般に解されていない。

住居不侵入等確保権の保護法益をめぐる学説の考え方

保護法益

- ・ **プライバシーの利益**等の人格的利益。
- ・ 財産権
- ・ 私生活上の安心・安全（←私生活上の自由）

保護の客体

- ・ 「住居、書類及び所持品」という有体物に限定という見解（今日では少数説）。
- ・ 「住居、書類及び所持品」は例示で無体物の情報も含まれるという見解。
 - ⇒ 音声の傍受や会話の盗聴等の行為（一定の情報を収集・取得する行為）にも住居不侵入等確保権の保護が及ぶ。

検討

- ・ 保護法益にプライバシーの利益や私生活上の安心・安全を含めて解する限り、「住居、書類及び所持品」は例示列挙と解することが合理的で、無体物も排除されない。

憲法35条1項の法意をめぐる主な学説(1)

手続的権利説

- ・ 住居、書類及び所持品について、侵入、搜索及び押収を受けることのない権利（住居不侵入等確保権）は、**刑事手続に関する手続的権利**を定めたものと解する見解。
- ・ これによれば、「住居、書類及び所持品」への物理的な不侵入等の確保に対する権利が刑事手続上剥奪される場合における令状主義の原則を定めたものとなる。
- ・ 住居不侵入等確保権については、それが制約される場合に関する一定の手続的要件（令状主義）が明示されている以上、憲法13条の予定する「公共の福祉」の確保の必要性に基づく制約は許されないという思想。
- ・ なお、条文上、令状主義が妥当する行為は「住居、書類及び所持品に対する侵入、搜索及び押収」であるが、それよりも機微性が高い「身体に対する侵入、搜索及び押収」（身体検査等）も令状手続が必要と解されている。

※判例も、強制採尿に関して、「体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は搜索・差押の性質を有するものとみるべきであるから、捜査機関がこれを実施するには搜索差押令状を必要とする」と説く（最決昭和55年10月23日刑集34巻5号300頁）。

憲法35条1項の法意をめぐる主な学説(2)

実体的権利説

- ・ 住居不侵入等確保権は、手続的権利としての側面だけでなく、「住居、書類及び所持品」に関する**個人のプライバシー保護**等を指向した実体的権利を保障する側面を有していると捉える見解。
- ・ 住居不侵入等確保権は、他の自由権と同様に、**あらゆる公権力の行使に対して**妥当するものであって、その保障範囲は権利を制約する手続の性質を問うものではない（刑事手続に限られない）。
- ・ これによれば、令状主義については、特に刑罰権の行使に関わる刑事手続との関係上、住居不侵入等確保権の不可侵性を「解除」するための手続的な要件を示したものの。
- ・ それゆえ、住居不侵入等確保権の保障に即して予定される手続は、令状主義にとどまらず、より広範な内容。例えば、(ア)居住者の立会い、(イ)夜間侵入の禁止、(ウ)身分証の提示等が基本的に求められ得る。
- ・ その結果、住居不侵入等確保権は、「あらゆる公的侵害に対する豊かな内容をもった基本的権利」として位置づけられ、行政警察（公衆衛生、労働基準監督等）や税務調査等もその侵害の対象となる。

憲法35条1項の法意をめぐる主な学説の検討(Ⅰ)

検討

- ・ 住居不侵入等確保権が私生活の本拠を尊重する理念に由来することを踏まえると、それに即した具体的な要請を含むものとして憲法35条1項が解釈されることが合理的。
- ・ 住居不侵入等確保権により保護される各人のプライバシー等に対する利益の最大化を念頭におきつつ、同時に「公共の福祉」を確保する観点から、捜査活動や行政調査活動の最適化・合理化等についても併せて考慮する必要（もっぱら刑事手続の局面に保護が限定されるわけではないと解される）。
- ・ 憲法31条が適正な手続を保障していると解される中で、憲法35条1項がもっぱら手続的権利を重疊的に保障したものと解するのは非合理的。

【憲法31条】

何人も、**法律の定める手続**によらなければ、その**生命若しくは自由を奪はれ**、又はその他の刑罰を科せられない。

- ・ 住居不侵入等確保権（公権力による不当な搜索等の禁止）という実体的権利の保障がまずあって、一定の局面において不可侵性を解除するのが令状手続にほかならず、手続的権利としての側面は当該局面を捉えたものと解することが条文の文理にも適合的。

憲法35条1項の法意をめぐる主な学説の検討(2)

- ・令状主義は、搜索等の実施に際しての絶対的なルールではなく、住居不侵入等確保権に対する「公共の福祉」の確保の必要性に基づく制約が求められる場合には、「第33条の場合」以外の場合であっても、例外的に無令状での搜索等が実施される余地を残したものの（ただし、憲法31条の趣旨に照らし、その余地についてはあらかじめ立法により特定・規律される必要）。

⇒憲法がさまざまな基本権のうち住居不侵入等確保権に限って「公共の福祉」に基づく内在的制約の可能性を否定している、という解釈を採る合理性は乏しい。

- ・そもそも手続的権利の保障は、それが支える実体的権利の内容と明確に区分し得るものではなく、住居不侵入等確保権におけるプライバシーの利益の要素（実体的権利としての要素）についても、手続の保障に一元化し得るものではない。
- ・仮に手続的権利説による場合、住居不侵入等確保権は刑事手続等においてのみ行使可能ということになるが、そのように適用の射程を限定する合理性は不明。

⇒憲法35条は、沿革的には、刑事手続上の捜査活動の統制を主に念頭において制定されたもの。実際、令状主義や「第33条の場合」については、主に刑事手続における搜索等が許容（正当化）される事由。しかし、通常の行政手続（刑事責任の追及を前提としない立入検査等）においても、プライバシーの利益等が著しく害される可能性があることにかんがみれば、住居不侵入等確保権は非刑事手続上も保護されると解することが合理的。

憲法35条1項の法意をめぐる主な学説の検討(3)

- ・ 憲法35条1項は、公権力の行使に常に令状が提示されることを保障しているのではなく、「侵入、搜索及び押収」に該当する行為が基本的に令状手続に服することを予定しつつ、住居不侵入等確保権が「侵されない」ことを定めている。よって、「侵入、搜索及び押収」に該当する行為の射程はどこまでか、またどのような場合に住居不侵入等確保権を「侵す」ことになるのか、といった点に関して、判断の余地が残されている。

⇒住居不侵入等確保権が単なる手続的権利ではなく、実体的権利であることの証左。

- ・ 仮に手続的権利説による場合、憲法35条1項が予定する令状主義の例外としての「第33条の場合」、手続的権利の不可侵性が「解除」されるため、無令状で行われ得る搜索等に対する別途の手続的な規範が（同条項からは）何ら読み取れない（逮捕の場合は、搜索等に対する手続的権利が何ら保障されないことになり得る）。

【憲法33条】

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

- ・ 手続的権利説が、刑事手続上「公共の福祉」に基づく内在的制約としての「令状主義の例外」を許容しないとすると、憲法35条1項の趣旨（住居不侵入等確保権）を非刑事手続にも適用させることが実質的に困難に。

「侵入、搜索及び押収」に該当する行為の射程

学説上の一般的な理解

- ・ 侵入：管理者の同意なしに物理的に立ち入ること。
- ・ 搜索：一定のものを探索する目的で住居や所持品等を点検すること。
- ・ 押収：一定のものの占有を強制的に得ること。

「侵入、搜索及び押収」に該当する行為

- ・ 憲法上の「侵入、搜索及び押収」（「搜索等」という）に該当するためには、上記の行為の類型に関し、「基本権又は基本権に関する法益に対する本質的な制約となる行為」という追加的要素が必要と解される。
 - ⇒上記の行為の類型のうち、基本権又は基本権に関する法益に対する強度な制約となるものが「侵入、搜索及び押収」に該当する行為。それ以外は「**搜索等近似行為**」。
- （例）警察官による宅配便荷物 of エックス線検査（最決平成21年9月28日刑集63巻7号868頁）
→**プライバシー**を本質的に制約→搜索等。
警察官による電話の傍受（最決平成11年12月16日刑集53巻9号1327頁）
→**通信の秘密・プライバシー**を本質的に制約→搜索等。

【参考】関連判例の判旨

宅配便エックス線検査事件

- ・ 本件エックス線検査は、荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について、捜査機関が、捜査目的を達成するため、荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察したものであるが、その射影によって荷物の内容物の形状や材質をうかがい知ることができる上、内容物によってはその品目等を相当程度具体的に特定することも可能であって、**荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害する**ものであるから、検証としての性質を有する強制処分に当たるものと解される。そして、本件エックス線検査については検証許可状の発付を得ることが可能だったのであって、**検証許可状によることなくこれを行った本件エックス線検査は、違法**であるといわざるを得ない。

電話傍受決定

- ・ 電話傍受は、**通信の秘密を侵害し、ひいては、個人のプライバシーを侵害する強制処分**であるが、一定の要件の下では、捜査の手段として憲法上全く許されないものではないと解すべき。

※通信傍受法制定前のもの。現在では法律に基づき通信傍受には傍受令状が要件化。

搜索等と搜索等近似行為との相違

⇒ 搜索等は刑事手続上の行為が多くなり得るが、非刑事手続上の行為を排除しているわけではないと考えられる。憲法は、憲法36条乃至40条の規定（刑事手続に関する規定）の趣旨に照らし、刑事手続と民事手続との区別を予定しているが、刑事手続とそれ以外の行政手続との区別をも当然に予定しているとは言い切れない。

- ・ 搜索等近似行為については、判例も、「**搜索に至らない程度の行為**」として無令状での実施を許容。

※ 警察官の職務質問に付随する**短時間の目視による所持品検査**は搜索等近似行為と解される（最判昭和53年6月20日刑集32巻4号670頁：バッグ所持品検査事件。最判昭和53年9月7日刑集32巻6号1672頁：ポケット所持品検査事件）。ただし、当人の私的情報を大量に収集し、その私生活の相当部分を明らかにし得ると認められる態様で所持品検査が実施される場合には、**プライバシー等に対する強度な制約**となるものとして、搜索等に該当する可能性がある。

- ・ 住居不侵入等確保権は、正当な手続に基づかない搜索等からの防御をその核心としつつも、そのみを保障するものではないと解される。搜索等近似行為も、その実施の態様によっては、搜索等該当性を有する行為に転化する可能性を秘めているからである。
- ・ 搜索等近似行為と搜索等該当性を有する行為とは、その分水嶺に関して紙一重となる部分があり、少なくとも語義としての「侵入、搜索及び押収」の類型に属する行為という点で共通するため、搜索等近似行為であっても、その継続的な実施等により私生活・私的行動の相当部分の把握に至れば、それは搜索等と位置づけられ得る。

搜索等に対する令状主義の要請

令状主義の機能

- ①国民の権利・利益の侵害の防止
- ②捜査機関等による不必要な権限の行使（濫用）の抑制

令状主義の射程：刑事手続上の行為が中心

- ・ 刑罰権の発動を予定する刑事手続上の行為については、特定の行政目的のための行政調査等に比べ、対象者に社会的な非難を伴う制裁を招く可能性を付与し、平穏な状態を妨害するため、権利制約度が強く、上記①の機能を作用させる必要性が相対的に高い。
- ・ また、捜査活動の領域には基本的に格別の限定がなく、一般的・狩猟的な搜索等が行われるリスクが高いことから、上記②の機能を作用させる必要性が相対的に高い。

⇒ 通常の行政手続の一環として搜索等が行われる場合には、「公共の福祉」を確保する観点から、必ずしも当然に令状手続に服することが憲法上要請されるわけではなく、法律に基づき他の合理的な手続が予定されることもあり得ると解される。

※憲法35条1項自体は憲法33条（逮捕）の場合を令状主義の例外と明示していることを根拠にして、立法による当該例外を創出する可能性を疑問視する見解もあるが、憲法上の当該例外は、憲法33条の場合のみに収斂しない。憲法13条の予定する「公共の福祉」についても、当該例外を構成する要素となり得る。

住居不侵入等確保権の保護範囲と令状主義の適用範囲との相違（I）

適用範囲の差異

- ・ 条文上、令状主義は搜索等に適用。**搜索等近似行為は令状主義の要請に服しない。**
- ・ しかし、搜索等近似行為であれば、令状主義から解放されるばかりか、住居不侵入等確保権の保障とは何ら関わりを有しなくなると解するのは合理的な解釈ではない。
- ・ むしろ、搜索等近似行為についても、搜索等の場合に準じた水準で、その不当又は不合理な実施が抑制されると解することが、住居不侵入等確保権の保障の趣旨に適合的。
- ・ 判例も、「所持品について搜索及び押収を受けることのない権利は憲法35条の保障するところであり、**搜索に至らない程度の行為であってもこれを受ける者の権利を害する**」と説示（前掲最判昭和53年6月20日）。不当な搜索等近似行為の実施が住居不侵入等確保権の侵害となり得ることを示唆。
- ・ よって、**住居不侵入等確保権の保障の対象は、搜索等のみならず、搜索等近似行為にも及び**、これらが不当又は不合理に実施されることに伴う脅威が防御される。
 - ⇒ 住居不侵入等確保権等の保障の対象範囲と令状主義の適用範囲とは必ずしも一致せず、前者の方が広い（非刑事手続を含む多様な公権力の行使に及ぶ）。

住居不侵入等確保権の保護範囲と令状主義の適用範囲との相違(2)

- ・判例は、憲法35条1項の規定について、「**主として刑事責任追及の手續における強制**について、それが司法権による事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨であるが、当該**手續が刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで、その手續における一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあると判断することは相当ではない**」と説く（最大判昭和47年11月22日刑集26巻9号554頁）。
- ・搜索等近似行為が（住居不侵入等確保権の侵害に至らずに）許容される具体的な範囲については、憲法13条が求める基本権の「最大の尊重」（それから導かれる比例原則）及び「公共の福祉」の確保の必要性を踏まえ、個別に判断される。
- ・判例も、「搜索に至らない程度の行為」（搜索等近似行為）としての所持品検査が許容される範囲について、「必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮」のうえ判断されると説く（前掲最判昭和53年9月7日）。

【参考】

- ・刑事手續と非刑事手續との関係に関しては、手續的権利説の根底に、憲法31条以下（同40条まで）の規定をすべて**刑事手續に関する手續的権利**の保障と解する思想がある。しかし、その思想は、少なくとも憲法32条の規定（裁判を受ける権利の保障）が刑事手續のみを視野に入れたものではないことに背反するし、憲法31条（や憲法35条1項）の適用も刑事手續の局面のみに限定されるわけではないという解釈に整合しない。

搜索等における令状主義の例外（Ⅰ）

令状主義の原則とその例外

- ・ 搜索等は令状主義の要請に服することが原則。
- ・ その例外として、憲法35条1項にいう「第33条の場合」（適法な逮捕）のほか、憲法13条に基づく「公共の福祉」の確保の必要性（捜査活動等の最適化等）を踏まえ、令状手続によらないことが適当と認められる場合。
- ・ 捜査活動等の最適化それ自体も、国民の安心・安全を確保する観点から重要となる公共の利益。令状主義に過度に拘束され、捜査活動等が著しく妨げられることとなれば、安心・安全が脅かされる結果を招来。
⇒基本権の「最大の尊重」（憲法13条）を図る観点から、本末転倒。

※手続的権利説の立場からは、住居不侵入等確保権の不可侵性の解除条件として令状主義が組み込まれている以上、「公共の福祉」に基づく制約を認める余地はないとされる。

⇒これによれば、令状主義に服することが予定された住居不侵入等確保権の保障は、既に捜査活動の利益との間で一定の調整が行われていることになる。

搜索等における令状主義の例外(2)

- ・ 包括的基本権を保障しつつ「公共の福祉」の確保を要請する憲法13条の規定が、住居不侵入等確保権の保障に限って「公共の福祉」に基づく制約を認めていないと解し得る合理的な理由は乏しい。
- ・ 特に、刑事手続以外の行政手続では、基本的に行政目的が特定されていることや、対象者が自ら（行政機関との相談等を通じて）適切な範囲に搜索等の実施を調整する余地が残されていることから、令状主義を絶対視する必要性が低い。
- ・ 憲法35条1項は「令状がなければ搜索等は一切実施されない」とは明示しておらず、「令状がなければ住居不侵入等確保権は侵されない」ことを明示。
 - ⇒ 具体的にどのような場合に「侵される」のかについては、「公共の福祉」の確保の必要性も踏まえた個別的な判断の余地を残している。
 - ⇒ 基本権に対する強度な制約となる搜索等について、正当な理由が認められ、かつ法律の予定する適正な手続（憲法31条参照）に沿って行われる限り、令状手続以外の手続に基づくものであっても、「侵す」ことにはならない。

搜索等における令状主義の例外(3)

- ・「令状がなければ、侵されない」とは、**令状手続を基本とすることを明示するもの**。住居不侵入等確保権の侵害は禁止される行為であるため、「令状があれば、侵してもよい」ないし「令状がある場合に限り、侵してもよい」という意味ではなく、「**令状があれば、住居不侵入等確保権は正当に制約される**」という旨を含意。「正当に制約される」場合として、令状手続以外の手続は排除されていない。
- ・ただし、憲法31条の規定の趣旨に照らし、搜索等に対する最低限の要請として、令状手続の詳細又は令状手続以外の適正な手続の内容については、立法化が必要。
- ・国税通則法に基づく税務調査や統計法に基づく立入検査（対象者が拒否すれば罰則）は、対象者の基本権を本質的に制約し得るが、その実施が無令状でも正当化されるのは、「公共の福祉」を確保する観点が考慮されたうえでの立法の合理性によるもの。
- ・判例も、法律に基づく税務調査としての無令状での強制的な検査について、憲法35条の法意に反しないと説示（前掲最大判昭和47年11月22日）。
- ・税関職員による無令状での国際郵便物の強制的な検査についても、国際社会で広く実施されていることを踏まえた高度な公益性を認め、憲法35条の法意に反しないと明示（最判平成28年12月9日刑集70巻8号806頁）。

搜索等における令状主義の例外(4)

- ・ 憲法35条 1 項における **令状主義の要請**は、憲法13条の規定（捜査活動の最適化等が「公共の福祉」の一内実をなすこと）を媒介として、**デフォルトルール化**。
 - 住居不侵入等確保権等の保障と令状主義との結びつきは、搜索等近似行為において切断されるうえに、搜索等においても一定の範囲で切り離される余地を残している。
- ・ それゆえ、ある刑事手続上の行為と非刑事手続上の類似する行為とがほぼ同等のプライバシーへの制約の程度を秘めている場合に、前者に令状主義を適用し、後者には適用しない立法が行われても、ただちに憲法35条 1 項の規定に反するものとはならない。
 - 判例が警察官による宅配便荷物のエックス線検査には令状（検証許可状）手続を求め、税関職員による国際郵便物の検査は無令状での実施を認めたのも、合理的。
- ※ 税関検査については、通関に固有の行政目的の実現に照らし、令状主義の例外が認められ、法律に基づく無令状での実施を認める手続も許容され得る（単に税関検査が非刑事手続であるから令状主義が適用されなくなるということではない）。

搜索等における令状主義の例外(5)

- ・ 以上の見解は、捜査機関等による権限の濫用を抑制する令状主義の機能を軽視するものではなく、住居不侵入等確保権の保障が原則として令状主義の要請を伴うことは不変。
- ・ 以下を摘示することに主眼。
 - ①令状主義といえども捜査活動の最適化等を織り込む「公共の福祉」の観点からの「例外」が皆無ではない
 - ②非刑事手続の局面においても住居不侵入等確保権等の保障が及ぶ、といった点を摘示。
- ・ 手続的統制という意味では、令状主義に加えて、憲法31条の要請及びそれを受けた強制処分法定主義（刑事訴訟法197条1項但書）という「二重の手続的統制」が機能。

【参考：刑事訴訟法197条】

捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これを行うことができない。

※判例上、強制の処分とは、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するもの」（最判昭和51年3月16日刑集30巻2号187頁）であり、「個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するもの」（最判平成29年3月15日刑集71巻3号13頁）がその核心。